

1527523-73.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... denúncias anônimas, fuga do suspeito e antecedentes no tráfico não são suficientes para o ingresso no domicílio. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. NULIDADE DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1527523-73.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527523-73.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308687/2021 - 26º D.P. SACOMA, 21353749 - 26º D.P. SACOMA, 4201/21/226 - 26º D.P. SACOMA, 2308687 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ORTIZ SIMAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

RAFAEL ORTIZ SIMAO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, supostamente na data de 11 de novembro de 2021, por volta de 13hs30min, no interior da residência localizada na Rua Bataguáçu, n.º 10, no bairro da Vila Maria, nesta Capital, foi surpreendido quando guardava e tinha em depósito, para fins de comércio ou entrega a consumo de terceiros, por ocasião de calamidade pública, 11 (onze) invólucros plásticos contendo, aproximadamente, 71.0 g (setenta e uma gramas) da substância Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", 39 (trinta e nove) frascos plásticos contendo, aproximadamente, 51.7 g (cinquenta e uma gramas e sete decigramas) da substância Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida

como "maconha", 01 (um) invólucro plástico (tablete) contendo, aproximadamente, 334.3 g (trezentas e trinta e quatro gramas e três decigramas) da substância Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", 12 (doze) microtubos plásticos do tipo "eppendorf" contendo, aproximadamente, 6,0 g (seis gramas) da substância cocaína, e 20 (vinte) comprimidos contendo, aproximadamente, 8.8g (oito gramas e oito decigramas) da substância Metilenodioximetanfetamina (MDMA), popularmente conhecida como "ecstasy", substâncias estas, drogas, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida às fls. 99/104, o acusado foi citado à fl. 190, apresentou defesa às fls. 152/163 e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal (fls. 174), momento em que ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu. Ao final, realizaram-se os debates.

Foi proferida sentença condenatória a fls. 208/212, em face da qual foi interposta apelação (fls. 224/241), na qual rejeitaram a preliminar e deram provimento parcial à apelação para reduzir a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da condenação, e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo (fls. 306/315).

Posteriormente, sobreveio acórdão em habeas corpus de fls. 342/355 que concedeu a ordem para anular as provas colhidas nos autos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

No caso em tela, a despeito da discussão quanto à propriedade e destinação da droga, o réu deve ser absolvido em razão da ilicitude da prova colhida nos autos, reconhecida em sede de habeas corpus, conforme acórdão de fls. 342/355, que por sua vez decorreu da ilegalidade na violação do seu domicílio.

Explico.

A teor do art. 5º, XI, da CF/88, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Da interpretação do referido dispositivo constitucional decorre que o ingresso no domicílio do réu seria admitido em três situações, conforme será esclarecido com maior profundidade adiante:

I) Se houvesse autorização judicial para tanto.

II) Se houvesse consentimento válido e inequívoco do morador.

III) Se houvesse fundadas razões concretas da ocorrência de flagrante delito no local e a urgência não permitisse a espera por mandado judicial.

Com a devida vênia aos respeitáveis entendimentos em contrário, entendo que nenhuma delas estava presente no caso em tela.

Vejam os.

I) AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

A ausência de autorização judicial para tanto é incontroversa.

II) CONSENTIMENTO DO MORADOR

O tema do consentimento do morador é ainda incipiente na doutrina e na jurisprudência pátrias, especialmente em razão da falta de especificação legal dos requisitos de sua validade, diferentemente do que ocorre em outros países, nos quais, além de haver regulamentação legal mais concreta, a doutrina e a jurisprudência já se debruçam sobre o tema há tempos. Cito como exemplo Espanha, Portugal, França e Estados Unidos.

Um dos poucos a escrever a respeito no Brasil, Pierpaolo Cruz Bottini, em artigo publicado no site Conjur<https://www.conjur.com.br/2014-nov-11/direito-defesa-buscas-policiais-mandado-parecem-normatizado>, assim discorre:

"Como pontua a doutrina processual penal, durante o dia ou à noite, o morador pode permitir a entrada em sua casa e, nessa situação, dispensa-se mandado judicial para realização de busca domiciliar. O consentimento, porém, deve ser real e livre, desprovido de vícios como o erro, violência ou intimidação.

Evidentemente que, em cada caso concreto, o consentimento do morador deve ser analisado com cautela e nunca presumido, especialmente para que se evitem abusos da autoridade policial. Sobre o cenário de muitos casos brasileiros, Cleunice Pitombo destaca: “Infelizmente, no Brasil e em outros lugares, em que o miúdo desconhece os próprios direitos, o abuso policial surge manifesto. A polícia invade casas e o morador, temeroso, tímido, não lhe coarctar o passo”.

O TJ-RS recentemente destacou a invalidade do consentimento de pessoa investigada por tráfico de drogas. Na ocasião, o desembargador relator pontuou: “Não existe previsão legal para a busca domiciliar a partir da permissão informal do proprietário. Do consentimento a que se refere o artigo 5º, XI, da Constituição Federal não se infere que poderão ser realizadas buscas sem determinação judicial, apenas sob a anuência do morador. Se assim fosse, veríamos-nos diante de um quadro temerário, no qual os mandados de busca e apreensão seriam dispensáveis, já que polícia sempre poderia conseguir, extrajudicialmente, o 'consentimento' do proprietário. Afinal, é de se ter em conta que, nas circunstâncias descritas nos autos esse aval foi dado sob constrangimento” (Ap 70058172628, relator desembargador Diógenes V. Hassan Ribeiro, 3ª Câmara Criminal, DJ 24.06.2014). Destarte, se há o consentimento do morador para buscas domiciliares, algumas questões devem ser bem refletidas: (i) forma do consentimento; (ii) pessoa que consente e seu grau de esclarecimento sobre as implicações da medida. Sobre a forma do consentimento, deve ser expresso e jamais presumido, sendo que não há previsão legal de forma especial. Relevante destacar doutrina portuguesa que pontua a necessidade de documentação do consentimento, por qualquer forma, mesmo gravada: “Relativamente à forma do consentimento, parece-nos resultar da lei que o mesmo não pode ser dado de forma tácita, nem por via de presunção. A exigência de consentimento expresso pode retirar-se da circunstância de a lei impor obrigatoriamente a documentação do mesmo. (...). Já no que respeita à forma de documentação do consentimento, o Acórdão da Relação de Lisboa de 13 de Janeiro de 2000 veio pronunciar-se no sentido de que a lei processual penal não exige forma especial (pode ser verbal), bastando que o mesmo seja prestado anteriormente à busca e fique, de qualquer forma, documentado. A documentação do consentimento verbal pode ser efetuada, por exemplo, através de gravação sonora”.([5]) No tocante à pessoa que consente, deve ser aquele titular do direito à inviolabilidade do domicílio. A doutrina destaca que a permissão deve ser do próprio sujeito da medida de busca e apreensão ou de outra pessoa que possa, legitimamente, representá-lo. Ressalvas são feitas, ainda, às habitações coletivas, em que o consentimento por um dos moradores não autoriza a busca na casa ou aposento de terceiros.([6])

No entanto, maior relevo tem a questão do grau de esclarecimento do morador que consentiu na realização da busca e apreensão. Para que se solucione o conflito de interesses – busca da verdade para realização da justiça e inviolabilidade do domicílio – por via consensual, é necessário que aquele que consente tenha pleno conhecimento das circunstâncias e consequências da realização da busca domiciliar, bem como que isso seja documentado.

No ponto, não há previsão legal. Contudo, tratando-se de medida que pode implicar a produção de prova contra o próprio morador que consente com a busca, para que ele decida de forma justa e válida se franqueará a entrada em sua residência, necessário que no mínimo lhe sejam esclarecidos seus direitos e o alcance da inviolabilidade do domicílio, bem como as consequências da realização da busca domiciliar. A mesma lógica e o mesmo cuidado são observados nos procedimentos de interrogatórios, tanto judicial quanto policial, a fim de garantir o direito da pessoa de não produzir prova contra si (deriva das previsões constitucionais – artigo 5º, LVII e LXII – e consagrado do Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º).

Nesse aspecto, surpreendem a doutrina e a jurisprudência espanhola, já sensibilizadas com a questão, ao sustentarem que o consentimento deve ser prestado em circunstâncias que garantam uma decisão consciente e ponderada pelo morador. Defendem, em resumo: “a) que o consentimento deve produzir-se em condições de serenidade e liberdade ambiental necessárias para autorizar a invasão de um direito

fundamental como a inviolabilidade de domicílio; b) que, atendendo ao caráter fundamental do direito tutelado, a diligência se inicie com a informação do visado sobre o alcance do direito à inviolabilidade do domicílio e de seus limites, e com uma pergunta clara e concisa sobre se o visado tolera ou não a intromissão; c) a presença de um 'letrado', para garantir a autenticidade da manifestação de vontade, evitando perguntas capciosas ou sugestivas, bem como qualquer forma de coação ou ameaça; d) que entre a solicitação do consentimento e a resposta, por parte do visado, medie um pedido de tempo suficiente para este meditar com calma sobre o assunto e compreenda o significado e alcance da sua resposta".

(...)

Conclui-se que a autorização para a violação do domicílio, nos casos de flagrante delito, depende de um estado de flagrância claro, constatado antes da invasão do domicílio e passível de demonstração posterior. As suspeitas, fundadas em relatos declarados ou ocultos, devem ser submetidas a prévia autorização judicial, mediante representação.

Além disso, no ponto do consentimento, necessária observância de cuidados, a fim de assegurar que este seja consciente e válido. Frise-se que o consentimento não se presume e requer prova, cujo ônus é do Estado (TRF-2 Região, RSE 200551015058355, DJ 22.10.2008). Mais do que isso, parece-nos essencial que sejam esclarecidos, ao sujeito da medida e de forma documentada, os seus direitos, o alcance da inviolabilidade do domicílio e as consequências de sua decisão por franquear a entrada de policiais para a busca domiciliar. Trata-se de medidas mínimas para coibir abusos da autoridade policial e fazer valer um Estado Democrático de Direito." (grifo não original).

Na jurisprudência dos tribunais superiores, o tema até pouco tempo atrás não vinha sendo enfrentado, salvo lateralmente em alguns casos.

O Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal levantou o problema em seu voto condutor no RE n. 603.616 (Tema 280 de Repercussão Geral), mas não o enfrentou a fundo por não ser o cerne do tema em julgamento:

"Outra questão não apreciada é a validade do consentimento do morador. As hipóteses concretas podem revelar desdobramentos complexos, seja quanto à prova do consentimento, seja quanto a sua validade e suficiência. A Suprema Corte dos Estados Unidos vê com desconfiança o consentimento do morador obtido pelo agente estatal "sob autoridade governamental" (under government authority) ou "sob as cores do uniforme" (under color of office) - respectivamente, casos *Amos v. United States*, 255 U.S. 313 (1921) e caso *Johnson v. United States* 333 U.S. 10 (1948). Já houve algum debate sobre o assunto no HC 79.512, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 16.12.1999. O tema em julgamento, no entanto, não se presta a resolver a questão" (RE n. 603.616, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe-093).

No Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, o tema também já foi trazido de passagem em alguns julgados:

"Por fim, merece destaque a afirmação constante dos autos de que, ao se dirigirem para a residência, os policiais tiveram a entrada franqueada pela proprietária do imóvel (fls. 3 e 256). Tal realidade, a meu ver, demonstra muito mais uma situação aguda, uma vontade externada sob domínio de intensa pressão, do que uma pouco crível colaboração para que, voluntariamente, fosse autorizado o ingresso de agentes policiais em sua residência para a busca domiciliar. Em relação ao cenário brasileiro, Cleunice Pitombo, na mesma linha, destaca: "Infelizmente, no Brasil e em outros lugares, em que o miúdo desconhece os próprios direitos, o abuso policial surge manifesto. A polícia invade casas e o morador, temeroso, tímido, não lhe coarctar o passo" (Da busca e apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 133-134)." (trecho do voto do Ministro Rogério Schietti por ocasião do julgamento do RESP Nº 1.690.854 - RJ)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PROTEÇÃO DO DOMICÍLIO (ART. 5º, XI, DA CF). ATUAÇÃO DE POLICIAIS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE. ILICITUDE DA PROVA. ENTRADA NO DOMICÍLIO FRANQUEADA PELA TIA DO PACIENTE, DIANTE DA ADVERTÊNCIA DE MONITORAMENTO POLICIAL PRÉVIO. INDIFERENÇA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PARECER MINISTERIAL

PELA CONCESSÃO DA ORDEM. (...) 4. No caso, embora a tia do paciente tenha franqueado a entrada dos policiais no imóvel da família, diante da advertência de monitoramento estatal prévio, a "autorização" não torna lícito o procedimento policial que, diante de denúncia anônima, não procedeu investigação preliminar para confirmar, ou não, os elementos de suspeita de autoria e de materialidade delitiva. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar a nulidade da prova, restabelecendo a sentença absolutória.

(...) No ponto, registro que a denúncia anônima não foi minimamente esclarecida nos autos pelos agentes públicos policiais e a suposta autorização para ingresso no imóvel, embora confirmada pela tia do réu, não é válida, tampouco concede licitude à ação policial, pois se trata de pessoa com desconhecimento da lei, desassistida de profissional da área jurídica, hipossuficiente frente ao aparato policial (DENARC) que, por si só, exerce coação com a mera presença e, portanto, compreensível que a tia do réu tenha lhes autorizado a entrada no imóvel sem o conhecimento acerca da inviolabilidade do domicílio que lhe assiste na condição de residente. (STJ - HC: 423653 RS 2017/0288292-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018)

No julgamento do REsp 1.558.004-RS, em 22.08.2017, o Ministro Rogério Schietti avançou um pouco mais sobre a questão dos requisitos de validade do consentimento citando o entendimento do Tribunal Supremo Espanhol a respeito:

"Sobre o específico tema do consentimento do interessado, o Tribunal Supremo espanhol decidiu, por mais de uma vez (SSTS. 1803/2002, 261/2006 e 951/2007), sobre a necessidade do preenchimento de requisitos para que a manifestação de vontade seja considerada válida, desprovida de pressão psicológica que a impeça de exercer seus direitos constitucionais, notadamente o previsto no art. 18.2 da Constituição da Espanha. Esse consentimento, "verdadera fuente de legitimación del acto de injerencia de los poderes públicos en el domicilio del imputado", decorre do próprio enunciado constitucional, como também do art. 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do art. 8 da Convenção de Roma e do art. 17 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Segundo a Corte espanhola, são os seguintes os requisitos a serem considerados para analisar o consentimento autorizado de ingresso no domicílio:

a) Outorga por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) Outorga consciente e livre, a qual requer: b1) que não esteja invalidada por erro, violência ou intimidação de qualquer modo; b2) que não seja condicionada a alguma circunstância periférica, como promessas de qualquer atuação policial; b3) que se o consentimento for de pessoa que estiver presa/conduzida, não pode validamente prestar o consentimento se não tiver antes a assistência de um defensor, do que constará da diligência policial (STS 2-12-1998). Isso porque se a assistência de defensor é necessária para que o conduzido preste declarações, dado o prejuízo aos seus direitos, o consentimento também o será, dada a "intimidação ambiental" ou "a coação que a presença dos agentes da atividade representa" (STS. 831/2000); c) Pode ser prestada oral ou por escrito, porém sempre vertida documentalmente; d) Deve ser outorgada expressamente, não servindo o silêncio como consentimento tácito, em face do princípio in dubio pro libertate (SS. 7.3 y 18.12.97 e S. 23.1.98). Sobre este item, refere o Tribunal Supremo que, embora autorizado o consentimento presumido pelo art. 551 do CPP espanhol, esse dispositivo "ha de interpretarse restrictivamente, pues el consentimiento tácito ha de constar de modo inequívoco mediante actos propios tanto de no oposición cuanto, y sobre todo, de colaboración, pues la duda sobre el consentimiento presunto hay que resolverla en favor de la no autorización, en virtud del principio in dubio libertas y el criterio declarado por el Tribunal Constitucional de interpretar siempre las normas en el sentido mas favorable a los derechos fundamentales de la persona, en este caso del titular de la morada" (STS 4761/2013); e) Deve ser outorgado pelo titular do domicílio. A relação jurídica entre o titular do direito e sua salvaguarda deve prevalecer, não sendo necessária a propriedade. Em caso de várias pessoas terem seu domicílio no mesmo lugar, não é necessário o consentimento de todos, bastando a anuência de

um dos cotitulares, desde que não tenha interesses contrapostos (STS. 779/2006); f) O consentimento deve ser outorgado para um caso concreto, sem que seja usado para fins distintos, ou seja, vigora a especialidade da busca (STS, sentença de 6 de junho de 2001); g) São dispensadas as formalidades exigidas no art. 569 da Ley de Enjuiciamiento Criminal (CPP da Espanha).

Esses requisitos, evidentemente, não têm sido nem sequer ventilados pela jurisprudência pátria, muito menos por leis de nosso país ou, ainda, por regramentos administrativos, mas refletem uma orientação que poderia ser adotada, na medida do possível, com vistas a minimizar a praxe, tão comum em comunidades de baixa renda, em que casas são ocasionalmente invadidas sem o amparo do Direito. Nesse sentido, aliás, caracterizou-se a intervenção do Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do RE n. 603.616/TO, em raciocínio paralelo ao que levou à edição da Súmula Vinculante n. 11, da qual se extrai a necessidade de documentar, por escrito, as razões que justificaram o uso de algemas em pessoa presa. É dizer, se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa – ostentando, portanto, verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção –, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria de demandar-se, em juízo de proporcionalidade, a legitimidade de igual providência para a invasão de um domicílio, quando, a priori, tem-se apenas a suspeita da ocorrência de um crime. Ainda em tom de reflexão, identifiquei dois desses requisitos exigidos pela jurisprudência do Tribunal Supremo da Espanha como merecedores de maior ênfase. O primeiro deles é o mencionado na alínea d, i. e., a outorga consciente e livre da autorização para o ingresso no domicílio, que, à evidência, pressupõe ausência de violência ou qualquer intimidação ou outra circunstância periférica "por parte da polícia. Note-se que a normativa pretoriana daquele país expressamente dispõe, se o consentimento provier de pessoa já presa ou conduzida, que a anuência do preso somente será válida caso ocorra com a assistência de um advogado. Com o intuito apenas de enriquecer a reflexão sobre o tema, menciono os termos da exigência judicial, na jurisprudência espanhola, da assistência do advogado ao réu detido em tal hipótese: El consentimiento a la realización de la diligencia, uno de los supuestos que permiten la injerencia en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, requiere que ha de ser prestado ante un letrado que le asista y ello porque esa manifestación de carácter personal que realiza el detenido puede afectar, indudablemente, a su derecho a la inviolabilidad y también a su derecho de defensa, a la articulación de su defensa en el proceso penal, para lo que ha de estar asesorado sobre el contenido y alcance del acto de naturaleza procesal que realiza" (STS 2-12-1998). Si la asistencia de letrado es necesaria para que éste preste declaración estando detenido, también le es necesaria para asesorarle si se encuentra en la misma situación para la prestación de dicho consentimiento, justificándose esta doctrina en que no puede considerarse plenamente libre el consentimiento así prestado en atención a lo que se ha venido denominándose "la intimidación ambiental" o "la coacción que la presencia de los agentes de la actividad representan" (STS. 831/2000 de 16.5). O segundo requisito que me parece importante sublinhar é o objeto da alínea e, supra, que regula a situação na qual diversas pessoas sejam atingidas pela violação do domicílio. Em semelhante hipótese, a jurisprudência espanhola se contenta com a autorização de uma pessoa, desde que seja cotitular do direito sob proteção. Assim, não se poderia validar o ingresso policial em uma residência se quem consentiu na entrada dos agentes da segurança pública era, por exemplo, pessoa não residente, mas apenas frequentadora do local. Atente-se para a circunstância, muito corriqueira, de que dentro de uma morada se encontram pessoas outras além do suspeito, as quais também são titulares do direito à preservação de sua intimidade e de sua dignidade, máxime quando se encontram no aconchego e na tranquilidade da noite, após uma jornada de trabalho, na companhia de crianças e de idosos, os quais, provavelmente, nenhuma responsabilidade têm na situação fática que ensejou a invasão do domicílio. (STJ - REsp: 1558004 RS 2015/0249614-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017)

Até que, mais recentemente, em paradigmático voto no julgamento do Habeas Corpus nº

598.051 SP, em 02.03.2021, o Ministro Rogério Schietti enfrentou com profundidade o problema, propondo como conclusão do julgado neste ponto que:

"3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo."

Tal entendimento, até então da 6ª Turma da Corte, foi acompanhado pela 5ª Turma em 30.03.2021, em julgado de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas. Segue o trecho da ementa relativo ao consentimento do morador:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. WRIT NÃO CONHECIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 3. Em recente julgamento no HC 598.051/SP, a Sexta Turma, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. 4. O eminente Relator entendeu ser imprescindível ao Judiciário, na falta de norma específica sobre o tema, proteger, contra o possível arbítrio de agentes estatais, o cidadão, sobretudo aquele morador das periferias dos grandes centros urbanos, onde rotineiramente há notícias de violação a direitos fundamentais. 5. Na hipótese em apreço, consta que o paciente e a corré, em razão de uma denúncia anônima de tráfico de drogas, foram abordados em via pública e submetidos a revista pessoal, não tendo sido nada encontrado com eles. Na sequência, foram conduzidos à residência do paciente, que teria franqueado a entrada dos policiais no imóvel. Todavia, a defesa afirma que não houve consentimento do morador e, na verdade, ele e sua namorada foram levados à força, algemados e sob coação, para dentro da casa, onde foram recolhidos os entorpecentes (110g de cocaína e 43g de maconha). 6. Como destacado no acórdão paradigma, "Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas - avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência cotidiana do que ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio libertas). Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador." 7. Na falta de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). (...) (STJ - HC: 616584 RS 2020/0257456-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

No caso em tela, não há qualquer prova nos autos de que tenha havido consentimento do réu, consentimento este que foi por ele negado em juízo.

E, ainda que tivesse havido consentimento, não foi demonstrado inequivocamente que ocorreu de forma voluntária e livre, sendo manifesta a coação ambiental/circunstancial/situacional/indireta que a abordagem realizada por policiais armados causa nos indivíduos, mormente naqueles desconhecedores de seus direitos mínimos.

Como destacou o Ministro Ribeiro Dantas no voto acima citado (HC 616.584-RS), "anote-se que a situação específica dos autos também permite supor que a "dita autorização" estaria viciada pela intimidação ambiental, já que os acusados foram algemados, colocados na viatura policial e estavam na presença de policiais fardados. Nesse passo, ausente a comprovação de que a autorização do morador foi

livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree)."

Uma comparação singela entre ramos do Direito pode ser elucidativa. No Direito do Consumidor, que lida com direitos meramente patrimoniais disponíveis em uma relação entre particulares, a manifestação de vontade do consumidor, ainda que feita por escrito, muitas vezes – até com razoável facilidade e mesmo de ofício – é anulada pelo Judiciário quando lhe é prejudicial em razão da disparidade de forças e da impossibilidade concreta de negociação. Por que então no Direito Penal, que lida com direitos indisponíveis de um indivíduo em face do Estado, considerar livre e válido o suposto consentimento do morador (em geral sequer documentado), cuja consequência é a imposição de uma pena privativa de liberdade de até 15 anos de reclusão (no caso do tráfico) sem absolutamente nenhum benefício em troca?

Em outras palavras: por que alguém que guarda objetos ilícitos que podem lhe custar até 15 anos de prisão consentiria com a entrada da polícia em sua casa para realização de busca, senão pelo desconhecimento do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio ou pelo temor do que poderia resultar de sua negativa, isto é, pela falta de condições concretas de negar, ainda que não haja coação direta por parte dos agentes policiais?

Foi o que o Ministro Rogerio Schietti, do STJ, asseverou no julgamento do HC 598.051-SP em 02.03.2021: "Nesse quadro, soa inverossímil a versão policial, ao narrar que o paciente teria mostrado onde residia – mesmo nada sendo encontrado em seu poder – e que teria franqueado a entrada em seu domicílio. Ora, um mínimo de vivência e bom senso sugerem a falta de credibilidade de tal versão. Será mesmo que uma pessoa sobre quem recai a suspeita de traficar drogas irá franquear a entrada na residência, onde está a droga escondida? A troca de que faria isso??"

Nessa linha de raciocínio, segundo precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos, a voluntariedade do consentimento deve ser aferida à luz das circunstâncias do caso concreto, isto é, analisando-se fatores subjetivos (relacionados ao sujeito do consentimento) e objetivos (relacionados ao contexto do consentimento) para verificar se houve voluntariedade na declaração de vontade ou se a declaração deriva de uma situação de coação, em que predomina o temor em detrimento da autonomia da vontade.

É importante notar que a coação/constrangimento ao sujeito pode ser involuntariamente provocada pelo aparato policial em virtude de simples circunstâncias objetivas da abordagem ou da condição pessoal do sujeito abordado, não devendo ser necessariamente relacionada à má-fé, ao abuso ou à truculência policial. Ou seja, não se trata de desmerecer a valorosa e honrosa atividade policial ou de presumir a prática de coações por parte dos policiais. O que se pondera, contudo, é o medo que os cidadãos em geral possuem de contrariar as autoridades estatais por conta do desconhecimento do que é ou não lícito e ao que estão ou não obrigados, circunstância esta que influencia na validade do consentimento.

O homem médio brasileiro, profundo desconhecedor de suas garantias mínimas, sente-se coagido diante de tal interpelação policial, sendo que às vezes dá permissão para a prática de atos pelos agentes do Estado, aos quais não está obrigado a se submeter, mas o faz por receio do que pode advir de sua negativa, e não por livre e consciente manifestação de vontade.

Lembra-se aqui da figura do metus publicae potestatis, consistente em uma "situação em que o cidadão atua com reverência e temor quando está diante de uma autoridade pública". Tal temor provocado no particular pela natureza do cargo ocupado pelo agente público em determinada interação (metus publicae potestatis) é considerado pela doutrina para diferenciar, por exemplo, a tipicidade das condutas de corrupção passiva (CP, art. 317 – solicitar) e concussão (CP, art. 316 – exigir) por agentes públicos.

Demonstrando concretamente esse medo, a pesquisa ICJ Brasil aferiu em 2016 que "56% dos brasileiros concordam que se deve fazer qualquer coisa que um policial pede, mesmo quando se discorda da requisição".

Foram considerações dessa ordem, aliás, que levaram a Suprema Corte dos Estados

Unidos, no caso *Miranda v. Arizona* 384 US 436 (1966), a exigir a advertência expressa quanto ao direito ao silêncio e à assistência por advogado pelo indivíduo preso, a fim de assegurar a voluntariedade de eventual confissão feita em delegacia, ambiente reconhecido como intimidador.

III) FUNDADAS RAZÕES CONCRETAS DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO NO LOCAL E INVIABILIDADE DE AGUARDAR UM MANDADO JUDICIAL EM RAZÃO DA URGÊNCIA DA SITUAÇÃO

III. a) Fundadas razões

A questão relativa às buscas domiciliares sem mandado foi objeto de tese de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 603.616, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Na tese firmada ficou assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”

Ocorre que as interpretações para o que seriam as “fundadas razões” têm sido distintas país afora, havendo ainda quem entenda ser suficiente para o ingresso sem mandado judicial o mero fato de tratar-se de crime permanente (art. 303, CPP). Entretanto, se a interpretação da tese firmada em repercussão geral gera tantas soluções diversas, entendo seja necessário socorrer-se à *ratio decidendi* do acórdão, que pode trazer maior clareza à hermenêutica judicial, embora não necessariamente leve a uma conclusão unânime nos tribunais brasileiros.

O Ministro Relator, ao iniciar seu voto aponta:

“A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal afirma sem ressalvas que as autoridades podem ingressar em domicílio, sem a autorização de seu dono, em hipóteses de flagrante delito de crime permanente. Pretendo demonstrar que essa tese esvazia a inviolabilidade domiciliar, contrariando a interpretação sistemática da própria Constituição e tratados de direitos humanos dos quais o país é signatário. Por isso, proporei evolução do entendimento”. (destacou-se)

Fixada, portanto, a premissa de que a hipótese de flagrante delito em caso de crime permanente, por si só, não justifica a entrada em domicílio sem o competente mandado, o que correspondia ao entendimento antigo e superado do Supremo.

O próprio Ministro Gilmar Mendes reconhece que a solução por ele proposta ainda trará lacunas, mas que o objetivo do julgado é tornar a jurisprudência coerente com a Constituição da República e os tratados de direitos humanos e criar uma cultura judicial em que os juízes analisem, a posteriori, a existência de um lastro mínimo de razões (provas) existentes antes do ingresso que justifiquem medidas invasivas sem a existência de mandado de busca e apreensão:

“A solução preconizada não tem a pretensão de resolver todos os problemas. A locução fundadas razões demandará esforço de concretização e interpretação. Haverá casos em que o policial julgará que dispõe de indícios suficientes para a medida e o Juízo decidirá em contrário”. (destacou-se)

Entretanto, ao longo do voto, e discorrendo sobre as abusividades que devem ser evitadas ou coibidas, ainda que a posteriori, o Relator joga alguma luz sobre a problemática.

Primeiramente, sobre a forma como a questão vinha sendo tratada pelos Tribunais Superiores até o momento, o Ministro Gilmar Mendes consignou:

“Por definição, nos crimes permanentes, há um intervalo entre a consumação e o exaurimento. Nesse intervalo, o crime está em curso. Assim, se dentro do local protegido o crime permanente está ocorrendo, o perpetrador estará cometendo o delito. Caracterizada a situação de flagrante, viável o ingresso forçado no domicílio. Assim, por exemplo, no crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/06 –, estando a droga depositada em uma determinada casa, o morador está em situação de flagrante delito, sendo passível de prisão em flagrante. Um policial poderia ingressar na residência, sem autorização judicial, e realizar a prisão. Essa interpretação, a despeito de tradicional em nosso direito, é insatisfatória”. (destacou-se)

Em sua proposta de avançar na interpretação do tema, apontou que:

“Do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto

ao sucesso da medida. Em verdade, dificilmente a certeza estará ao alcance da polícia. Se certeza do crime e de sua autoria houvesse, a diligência seria desnecessária (...) Considerado o entendimento atual, o policial ingressará na casa sem a certeza de que a situação de flagrante delito, de fato, ocorre. Se concretizar a prisão, poderá dar seu dever por cumprido. Em caso contrário, terá, ao menos em tese, incorrido no crime de violação de domicílio, majorado pela sua qualidade de funcionário público, agindo fora dos casos legais – art. 150, §2º, do CP. Ou seja, o policial estaria assumindo o risco de perpetrar um crime, salvo se tiver sucesso em sua diligência. Isso dá ao policial um perigoso incentivo. Ou desvenda o crime, ou responde pessoal e criminalmente pela violação de domicílio”. (destacou-se)

O Ministro Gilmar Mendes pondera, assim, que qualquer alegação por parte dos policiais de que tinham informações sobre a ocorrência de um crime afastaria a inviolabilidade domiciliar, e nos colocaria em situação de arbitrariedade, pois não se pode admitir que a constatação da situação de flagrância em momento posterior ao ingresso forçado justifique a medida. Dessa forma, obtempera:

“A proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois. O controle judicial da investigação criminal serve para compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública. Esse controle pode ser a priori – antes da adoção da medida que afeta direitos fundamentais – ou a posteriori – após a adoção da medida. No controle prévio, a adoção da medida deve ser precedida da expedição de uma ordem judicial. O juiz, terceiro imparcial, analisa a presença dos requisitos da medida e, se for o caso, autoriza sua realização. No controle a posteriori, a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito”. (destacou-se)

“Assim, voltando ao exemplo da droga mantida em depósito em residência, se o policial obtém, mediante denúncia anônima, a informação de que a droga está naquela casa, não poderá pedir mandado judicial, porque ninguém se responsabilizou validamente pela declaração – art. 5º, IV, CF. (...) Em consequência, resta fortalecer o controle a posteriori, exigindo dos policiais a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa. Ou seja, que havia elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação que autoriza o ingresso forçado em domicílio estava presente”. (destacou-se)

Por fim, ao tratar de quais elementos poderiam ser considerados como justa causa a afastar a garantia de inviolabilidade de domicílio, o Relator aponta:

“Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio. No entanto, ao ouvir gritos de socorro e ruídos característicos de uma briga vindos de dentro de uma residência, o policial tem fundadas razões para crer que algum crime está em andamento no ambiente doméstico. Não se deve exigir que busque confirmação adicional para agir. Por outro lado, provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa”. (destacou-se)

Tem-se, dessa forma, que o próprio acórdão da tese de Repercussão Geral, embora afirme que os contornos concretos de sua decisão seriam delimitados com o passar do tempo, de antemão já aponta situações que não configurariam justa causa, ou, na locução da tese “fundadas razões”, como denúncias anônimas, pois é prova não passível de ser repetida e contraditada em juízo.

A leitura do voto e das discussões realizadas pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal aponta que à época do julgamento houve a preocupação de limitar o arbítrio estatal, garantindo a inviolabilidade do domicílio, principalmente das populações mais humildes e vulneráveis, mantendo a atuação policial em prol da

segurança pública de forma a criar, inclusive, espaço de garantia para a força policial a fim de que ela não responda por delitos de invasão de domicílio. Outra preocupação dos Ministros era não esgotar as hipóteses em que seria razoável o ingresso forçado em domicílio, pois os casos concretos são mais amplos do que uma tese abstrata pode fixar. Deixaram, assim, e expressamente, o campo aberto para formação de jurisprudência sobre o tema.

E nesse sentido é que a jurisprudência das duas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado, à luz da ratio decidendi do acórdão, tentando dar concretude ao conceito de “fundadas razões” a fim de evitar se converter em salvo conduto para que se ingresse em qualquer residência à procura de drogas sem fundamentos sólidos prévios (“fishing expeditions”).

Atualmente, é absolutamente pacífico no STJ o entendimento de que denúncias anônimas, fuga do suspeito e antecedentes no tráfico não são suficientes para o ingresso no domicílio. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA OBTIDA E DAQUELAS DELA DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protraí-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito. 2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida. 3. A prova obtida com violação à norma constitucional é imprestável a legitimar os atos dela derivados. 4. Recurso especial provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio e dela derivadas, por conseguinte, absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, II, do CPP. (REsp 1871856/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) (destacou-se). (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui jurisprudência no sentido de que “A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si só, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial” (RHC 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020) (destacou-se).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL E SEM ELEMENTOS MÍNIMOS DE TRAFICÂNCIA NO LOCAL. PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.

1. Ainda que esta Sexta Turma tenha admitido como fundamento para a prisão preventiva a relevante quantidade entorpecentes apreendidos em poder da paciente, tratando-se de 132 pedras de crack, 84 papelotes de cocaína e ainda 26 trouxinhas de maconha, não foi apontado nenhum elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência da paciente, citando-se apenas a verificação de denúncias de tráfico de drogas que receberam através do “Disque Denúncia”, e a fuga do adolescente.

2. Verifica-se ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, determinado no art. 5º, inc. XI, da Constituição da República, quando não há referência a prévia investigação policial para verificar a possível veracidade das informações recebidas, não se tratando de averiguação de informações concretas e robustas acerca da traficância no domicílio violado. (STJ, Sexta Turma, RHC 83.501/SP, Rel. Mini. Nefi Cordeiro, julgado em 06/03/2018)

(,...) Somente a informação de que o paciente tivera envolvimento anterior com tráfico de drogas não autoriza a autoridade policial a conduzi-lo até seu local de trabalho e sua residência, locais protegidos pela garantia constitucional do art. 5º, IX, da CF, para ali efetuar busca, sem prévia autorização judicial e sem seu

consentimento, diante da inexistência de fundamento suficiente para levar à conclusão de que, naqueles locais, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Precedente: (HC 527.161/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019) (destacou-se).

Sobre as denúncias anônimas, aliás, destaco que, em geral, não são aceitas pela jurisprudência dos tribunais superiores sequer como fundamento suficiente para expedição de mandado de busca e apreensão, muito menos para o ingresso no domicílio sem mandado judicial. Ou seja, com base apenas em denúncias anônimas nem o juiz pode autorizar a invasão domiciliar, muito menos o policial. Vejamos:

"[...] denúncia anônima não é fonte probatória, mas mera informação, passível de gerar movimentação investigatória preliminar, mas jamais fundamento para a restrição a direitos individuais" [STJ: RHC n. 53134/RJ. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe: 26/05/2015].

Isso não significa desprezar a importância de denúncias anônimas ou ignorar o fato de que muitas vezes são feitas de forma anônima justamente pelo temor que o denunciante tem de ser identificado perante os potenciais criminosos denunciados. No entanto, por serem anônimas, além de não poderem ser submetidas ao contraditório e à ampla defesa, o denunciante não está sujeito a nenhum tipo de responsabilidade caso preste informações falsas, diferentemente de testemunhas identificadas, que estão sujeitas ao crime de falso testemunho (art. 342, CP). E denúncias falsas podem ser (e infelizmente são) feitas pelos mais diversos motivos, desde trotes de adolescentes até pessoas mal-intencionadas com o único objetivo de causar constrangimento a inocentes com quem tenham alguma inimizade. As estatísticas oficiais mostram, por exemplo, que cerca de 15 a 20% das ligações recebidas pela PMSP via 190 são trotes, o que equivale a aproximadamente 5 mil chamadas por dia. <https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/pm-sp-trote.html> <https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/20-dos-atendimentos-da-pm-sao-trotes/> <https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/regiao/NOT,0,0,1437131,trotes+representam+15+das+chamadas+da+policia+militar.aspx>

Por isso, denúncias anônimas não podem ser suficientes para embasar imediatamente medidas invasivas, mas tão somente para dar início a diligências preliminares de averiguação, tais como campanhas, por exemplo.

Também não se mostra adequado o corriqueiro argumento a posteriori no sentido de que: "tanto a denúncia anônima era verdadeira e confiável que as drogas foram realmente encontradas". Tal argumento, contudo, ignora a premissa fundamental de que esses fatos só chegam ao conhecimento do Judiciário quando as denúncias se confirmam e objetos ilícitos são efetivamente encontrados, deixando uma enorme cifra oculta de casos em que casas foram invadidas, privacidades violadas, mas nunca tomaremos conhecimento porque nada de ilícito foi encontrado e nenhum procedimento formal instaurado.

E é justamente por isso que a Constituição atribui em regra ao juiz, um terceiro imparcial, a atribuição de analisar os elementos trazidos pela polícia e verificar se é possível ou não relativizar a inviolabilidade domiciliar.

O voto-vista do Ministro Rogério Schietti Cruz no RHC 83501/SP bem esclarece a situação: "Não se há de admitir, portanto, que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. Ora, se o próprio juiz (um "terceiro neutro e desinteressado") só pode determinar a busca e apreensão durante o dia e, mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente."

Por fim, destaco que o fato de o portão da residência encontrar-se aberto também não basta para o ingresso na residência, pois não retira a inviolabilidade do domicílio. Vejamos trecho elucidativo do voto do Ministro Nefi Cordeiro no